Check for updates

Received: 31 August 2022 | Accepted: 9 November 2022
DOI: 10.1111/reel.12482

SPECIAL ISSUE ARTICLE

RECIEL Review of European, Comparative & International Environmental Law WILEY

投资者与国家争端解决和东道国反诉对于履行气候变化国际责任的适用性

迭戈·梅希亚-莱莫斯

西安交通大学，西安，陕西，中国

通讯作者：Diego Mejía-Lemos，西安交通大学，地址：中国陕西省西安市咸宁西路 28 号，邮编：710049。电子邮件：d.ml@nyu.edu

抽象的

本文基于对文献、国际决定和文书的全面审查，探讨了投资者与国家争端解决（ISDS）对于履行因违反气候变化义务而产生的国际责任的适用性，特别关注东道国在 ISDS 仲裁程序中提出的反诉。 ISDS 可能适合这些目的，特别是由于 ISDS 仲裁程序的灵活性和混合性以及 ISDS 仲裁裁决的可执行性。 ISDS 的灵活性使得程序框架比其他形式的国际争端解决更具适应性。 ISDS 的混合性结合了国内和国际法律规则，为气候变化索赔或反索赔提供了单独运作的国家或国际法所无法提供的理由。至关重要的是，尽管 ISDS 的临时性质存在固有的局限性，但 ISDS 仲裁裁决的可执行性为有效履行违反气候变化义务的国际责任提供了无与伦比的机会。

1 | introduction

学术界越来越关注国际仲裁在解决涉及环境问题的国际法争端中的潜在和实际作用，特别是有关气候变化的争端。[1]各种组织都讨论了这些作用，包括联合国 (UN) 等政府间组织——最突出的是通过联合国国际贸易法委员会 (UNCITRAL) 第三工作组、投资者与国家争端解决 (ISDS) 改革 (WGIII)、[2] 经济合作与发展组织（经合组织）[3] 和常设仲裁法院 (PCA)，[4] 以及国际商会 (ICC)[5] 和国际法研究所 (IIL) 等非政府组织。[6]

[1]The survey underpinning this article's findings is comprehensive only to the extent materials specifically addressing the intersection of ISDS arbitral proceedings and counterclaims published as of November 2022 are concerned.

[2]UNCITRAL 'Possible Reform of Investor-State Dispute Settlement (ISDS): Multiple Proceedings and Counterclaims' UN Doc A/CN.9/WG.III/WP.193 (22 January 2020).

[3]OECD (ed), 'Submissions to the OECD Public Consultation on Investment Treaties and Climate Change' (OECD 2022).

[4]The PCA adopted two sets of 'environmental' conciliation and arbitration rules in 2001. PCA, 'PCA Optional Rules for Arbitration of Disputes Relating to Natural Resources and/or the Environment' in PCA (ed), *Permanent Court of Arbitration – Basic Documents: Conventions, Rules, Model Clauses and Guidelines* (2nd edn, PCA 2005) 179. For a comment on the PCA's potential roles in the settlement of environmental disputes, see P Sands and R MacKenzie, 'Guidelines for Negotiating and Drafting Dispute Settlement Clauses for International Environmental Agreements' in PCA (ed), *International Investments and Protection of the Environment* (Kluwer 2001) 305.

[5]The ICC has examined the role of international arbitration alongside that of other alternative dispute resolution (ADR) methods. International Chamber of Commerce (ICC) Commission on Arbitration and ADR, 'Resolving Climate Change Related Disputes through Arbitration and ADR: ICC Commission Report' (2019). For a similar analysis, see P Thieffry, 'International Arbitration of Climate-Related Disputes: Prospects for Alternative Dispute Resolution' in I Alogna, C Bakker and JP Gauci (eds), *Climate Change Litigation: Global Perspectives* (Brill 2021) 462,

[6]IIL, 'Resolution on Equality of Parties before International Investment Tribunals' 18 RES EN (31 August 2019). The IIL resolution in question was based on preparatory work under the rapporteurship of McLachlan. See CA McLachlan (Rapporteur), 'Equality of Parties before International Investment Tribunals' (Preparatory Work) in *Report 2018* (IIL 2018) 409 <https://www.idi-iil.org/app/uploads/2019/06/Commission-18-Equality-of-parties-before-international-investment-tribunals-McLachlan-Travaux-La-Haye-2019.pdf>.

国际商会认为，考虑到“气候变化的国际影响以及国家或国家实体可能作为当事方”，一般而言，国际仲裁适合解决涉及气候变化问题的争端。[7]国际仲裁已被纳入《联合国气候变化框架公约》(UNFCCC)，作为解决国家间争端的其他手段之一，[8]《巴黎协定》重申了这一选项。[9]事实上，开创性的特雷尔冶炼厂案是一个国家间广告临时仲裁。[10]国际仲裁不仅可以解决如上所述的国家间争端，而且还可以解决涉及非国家法人的争端。在这方面，ISDS 至关重要。事实上，ISDS 主要采取混合国际仲裁程序的形式，仲裁庭通常根据不同范围的适用国际投资协议临时组成，并在国际商会、解决投资争端国际中心 (ICSID) 和常设仲裁法院等各种仲裁机构的支持下运作。[11]

学术著作更具体地探讨了 ISDS 对于解决涉及环境和气候变化相关问题的争端的适用性。[12]作为介绍，值得回顾的是，气候变化法规范了越来越广泛和独特的环境问题子集，并且主要关注减缓和适应气候变化的措施。[13]环境和气候变化相关问题之间的这种“属与种”关系反映在投资条约实践中。例如，能源宪章条约 (ECT)，[14] 一项包含投资条款的多边条约，[15] 指的是《联合国气候变化框架公约》和“其他国际条约”与能源相关方面的环境协议”[16]，并将“环境影响”定义为“特定活动对环境造成的任何影响，包括……气候”。[17]

此外，在评估 ISDS 在这方面的地位时，必须记住，ISDS 仲裁庭通常仅对涉及投资者及其在适用投资条约下的投资的争议拥有管辖权，因此原则上，在非投资者或非投资相关问题上发挥的作用（如果有的话）有限。[18]抛开这些管辖权限制，ISDS 的设计和实践方式还存在其他限制。事实上，正如最初设想的那样，ISDS 几乎完全、单向地用于保护投资者及其投资，允许投资者在国际层面上直接针对东道国违反国际投资协定义务的行为寻求救济，特别是不必依赖投资者母国的外交保护。而且，与国际经济法（例如贸易）的其他领域相比，ISDS 仲裁庭处理环境问题的方式差异很大，导致“采取零敲碎打的做法，但往往做出相互矛盾的决定”。[19]

尽管存在这些限制，学者和机构经常确认，鉴于通常提交国际仲裁的标的种类繁多，ISDS仲裁程序适合处理环境和气候变化相关问题，其程序灵活性使其适用于解决非投资问题。[20]具体而言，一些人认为ISDS比国家间争端解决更适合处理此类问题，无论是仲裁还是司法。ISDS 比国家间争端解决更适用的主要因素包括缺乏专门处理环境争端的国际法院和法庭，更重要的是，国家间仲裁和司法程序所产生的裁决的执行受到限制。正如国际商会指出的，由于“缺乏国际环境法院”，环境纠纷被提交给“各种国际法院和法庭”。[21]然而，根据国际商会的说法，此类国际法院和法庭的诉讼程序，特别是国家间诉讼程序，带来了挑战

[7]ICC (n 5) 17, para 4.4.

[8]United Nations Framework Convention on Climate Change (adopted 29 May 1992, entered into force 21 March 1994) 1771 UNTS 107 (UNFCCC) art 14.

[9]Paris Agreement (adopted 12 December 2015, entered into force 4 November 2016) 3156 UNTS 107 art 24.

[10]*Trail Smelter (United States v Canada)* (Award) (11 March 1941) 3 RIAA 1905, cited in ICC (n 5) 60, para 51. For a more recent instance of an inter-State arbitration involving environmental matters and touching, albeit tangentially, on climate change issues, see *Indus Waters Kishenganga Arbitration (Pakistan v India)* (Final Award) PCA Case No 2011-01 (20 December 2013) para 117 (noting ‘the Court [of Arbitration] is cognizant that flows in the Kishenganga/Neelum may come to differ, perhaps significantly, from the historical record as a result of factors beyond the control of either Party, including climate change’).

[11]D Mejía-Lemos, ‘General International Law and International Investment Law: A Systematic Analysis of Interactions in Arbitral Practice’ in J Chaisse, L Choukroune and S Jusoh (eds), *Handbook of International Investment Law and Policy* (Springer 2021) 1603, 1604–1605.

[12]MC Cordonier Segger et al, ‘The International Law and Policy Implications of Climate Change Litigation: Sustainable Developments in International Investment Law and Policy Related to Renewable Energy, Climate Change Mitigation and Adaptation’ in W Kahl and MP Weller (eds), *Climate Change Litigation: A Handbook* (Bloomsbury 2021) 166; A Bilanová, ‘Environmental Counterclaims in Investment Arbitration’ (2020) 5 European Investment Law and Arbitration Review 400; CM Nwankwo, ‘Balancing International Investment Law and Climate Change in Africa: Assessing Vertical and Horizontal Norms’ (2020) 17 Manchester Journal of International Economic Law 48; SZ Vasani and N Allen, ‘No Green without More Green: The Importance of Protecting FDI through International Investment Law to Meet the Climate Change Challenge’ (2020) 5 European Investment Law and Arbitration Review 3, 3.

[13]See, among others, B Mayer, *The International Law on Climate Change* (Cambridge University Press 2018) 12 (noting ‘[t]he international law on climate change consists of specific treaty rules as well as general norms of customary international law’, notably ‘promoting climate change mitigation and providing support for climate change adaptation’); P Sands and J Peel, *Principles of International Environmental Law* (4th edn, Cambridge University Press 2018) 295 (noting ‘international law on climate change constitutes a vast field in its own right’).

[14]Energy Charter Treaty (adopted 17 December 1994, entered into force 16 April 1998) 2080 UNTS 100 (ECT).

[15]D Mejía-Lemos, ‘Article 10: Promotion, Protection and Treatment of Investments’ in R Leal-Arcas (ed), *Commentary on the Energy Charter Treaty* (Edward Elgar 2018) 150, 156, para 10.04.

[16]ECT (n 14) preamble.

[17]ibid art 19(3)(b) (as well as ‘the interactions among these factors’). Furthermore, climate change is a major aspect of the ongoing process of ‘modernization’ of the ECT. Energy Charter Conference ‘Finalisation of the negotiations on the Modernisation of the Energy Charter Treaty’ (24 June 2022) <https://www.energychartertreaty.org/modernisation-of-the-treaty/> (noting, among others, that climate change is an aspect expressly contemplated in various proposed amendments to ECT provisions, on a ‘Definition of Indirect Expropriation’, the ‘Right to regulate’ and ‘Sustainable development and corporate social responsibility’).

[18]Mejía-Lemos (n 11) 1617 (noting such treaties ‘not only are … a source of particular law norms, and of obligations thereunder, but also a source of jurisdiction of arbitral tribunals constituted’ thereunder).

[19]Sands and Peel (n 13) 915 (adding that, consequently, in ISDS arbitral proceedings the ‘parties’ choice of arbitrators … is likely to remain critical to the outcome of particular disputes’).

[20]J Rudall, ‘Green Shoots in a Barren World: Recent Developments in International Investment Law’ (2020) 67 Netherlands International Law Review 453, 468.

[21]ICC (n 5) 17, para 4.5.

20508394, 2023, 2, Downloaded from https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/reel.12482 by Cochrane Sweden, Wiley Online Library on [08/03/2026]. See the Terms and Conditions (https://onlinelibrary.wiley.com/terms-and-conditions) on Wiley Online Library for rules of use; OA articles are governed by the applicable Creative Commons License

[22]事实上，值得注意的是，《巴黎协定》缺乏执行机制，[23]因此可能会损害其义务的履行。[24]相比之下，至关重要的是，ISDS 仲裁程序受益于仲裁裁决的可执行性，[25]主要是根据《纽约公约》[26]或《ICSID 公约》。[27]

在 ISDS 仲裁程序中使用反诉来解决环境和气候变化相关问题已受到越来越多的关注。最值得注意的是，鉴于厄瓜多尔在 Perenco 诉厄瓜多尔[28] 和 Burlington 诉厄瓜多尔[29] 案中成功提出反诉，导致第一个公开的仲裁裁决要求投资者对环境损害负责，[30] 并且更根本地表明，ISDS 典型的单向特征并不妨碍东道国在某些情况下获得赔偿。学者们认为，此类反诉可能对提出毫无根据或无聊的主张具有威慑作用。特别是，反诉可能会阻止针对东道国气候变化相关措施的索赔以及毫无根据的索赔。[31]事实上，反索赔已被用来阻止无意义的索赔，正如秘鲁在 CCTE 诉秘鲁一案中对反索赔的依赖所证明的那样。[32]此外，反索赔通常被认为是减少欠投资者赔偿金额的一种手段。[33]因此，反索赔被认为是控股投资者的合适手段对其与环境有关的行为负责，总体上和范围内

ISDS,[34] 可能同样适用于涉及气候变化因素的争端。

在这方面，从国际责任的角度正确处理投资者行为的重要性至关重要，因为 ISDS 仲裁庭通常根据国家责任法来处理此类行为的法律后果，尽管一些学者几乎完全依赖开放式的“问责制”概念。[35]正如 Perenco 法庭所观察到的，如果反诉有理有据，则必须向做出反诉的国家提供全额赔偿反诉。[36]因此，Perenco 法庭任命了独立环境专家来确定赔偿金额。[37]

因此，ISDS 仲裁程序的灵活性和混合性以及 ISDS 仲裁裁决的更大可执行性凸显了 ISDS 在解决投资争端的气候变化方面的潜力。大多数其他国际争端解决机制通常是国家间的，必然仅限于追究国家责任。相比之下，ISDS 可以提供一个论坛，让私营实体对违反气候变化相关义务（包括最初根据国内法产生的义务）承担责任。事实上，后者的义务最初可能是由国内法规则产生的，这些规则可以作为适用投资协议下的义务来源而被援引，投资协议是 ISDS 仲裁程序的主要法律渊源。[38]ISDS 规定，援引东道国国内法的可能性可能是追究私人实体责任的关键。虽然大多数条约通常只为国家规定义务，并且不规定国家国内法的适用，就像投资条约下的多边环境协定一样，[39]但私营实体可以直接承担源自东道国国内法的气候变化义务，前提是可以根据适用的投资条约援引该国内法，正如伯灵顿和佩伦科案所示。

本文基于对中文、英文、法文、意大利文和西班牙文文献的全面回顾，考虑到 ISDS 仲裁程序作为履行国际责任机制的特点，对所审查文献中确定的突出问题进行了研究。其余部分分为五个部分。第 2 节详细阐述了国际关系的性质

[22]ibid. See also A Altchiler, ‘Using Investor-State Dispute Settlement to Enforce International Environmental Commitments’ (2021) 41 Pace Law Review 256, 273 (stating, in relation to ‘a variety of international agreements or policies under which parties have committed to combat climate change’, that ‘[l]arge portions of these agreements, however, are unenforceable’).

[23]M Anning, ‘Counterclaims Admissibility in Investment Arbitration: The Case of Environmental Disputes’ in Chaisse et al (n 11) 1277, 1286.

[24]This challenge has arguably been faced by international environmental law dispute settlement in general. J Rinceanu, ‘Enforcement Mechanisms in International Environmental Law: Quo Vadunt?’ (2000) 15 Journal of Environmental Law and Litigation 147, 155. See also Altchiler (n 22) 275 (arguing ‘ISDS could present an opportunity for investors to enforce states’ commitments’, since ‘the Paris Agreement and the EU Directive 2018/2001/EC both provide enforcement mechanisms for the procedural requirements of the agreement, but neither provide for a way to enforce the parties' substantive commitments to limit GHG emissions or promote renewable energy to a specific target’).

[25]ibid.

[26]Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards (adopted 10 June 1958, entered into force 7 June 1959) 330 UNTS 3 (New York Convention).

[27]Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of Other States (adopted 18 March 1965, entered into force 14 October 1966) 575 UNTS 159 (ICSID Convention).

[28]*Perenco Ecuador Ltd v The Republic of Ecuador and Empresa Estatal Petróleos del Ecuador*, ICSID Case No ARB/08/6 (*Perenco v Ecuador*), including the following decisions: Interim Decision on the Environmental Counterclaim (11 August 2015); Final Award (27 September 2019).

[29]韩秀丽 (Hán Xiùlì), ‘中国海外投资的环境保护问题: 基于投资法维度的考察’ (‘Zhōngguó hǎiwài tóuzī de huánjìng bǎohù wèntí: jīyú tóuzī fǎ wéidù de kǎochá’) 3 厦门大学学报 (Xiàmén dàxué xuébào) (2018) 148, 156; Rudall (n 20) 465.

[30]Rudall (n 20) 465.

[31]A Monti and L Nordlander, ‘OECD Public Consultation on Investment Treaties and Climate Change’ in OECD (n 3) 175, 178 (noting counterclaims ‘might deter investors from challenging States’ climate measures at all, in order not to be targeted by potential host State's counterclaims’).

[32]*Caraveli Cotaruse Transmisora de Energía v Republic of Peru*, ICSID Case No ARB/11/9, discussed in J Calvert, ‘Reforming IIAs to Combat Climate Change: Lessons from Latin America’ in OECD (n 3) 37, 39, para 3.2.

[33]Calvert (n 32) 39, para 3.2 (noting Ecuador's reliance thereon to ‘reduce the overall compensation owed to foreign owned oil companies’); Y Zheng and NJ Calamita, ‘The Essential Importance of Issues of Compensation and the Calculation of Quantum’ in OECD (n 3) 256, 262.

[34]N Monebhurrun, ‘La demande reconventionnelle comme procédure permettant d'engager la responsabilité environnementale des investisseurs: l'exemple du droit international des investissements’ (2020) 45 Revue juridique de l'environnement 526.

[35]KE Boon and F Mégret, ‘New Approaches to the Accountability of International Organizations’ (2019) 16 International Organizations Law Review 1, 5 (noting ‘[a]ccountability is not the same thing as a narrow international legal notion of IO responsibility and designates a wide range of processes’, instead.) However, several scholars rely on the wider notion of ‘accountability’. Calvert (n 32) 39, para 3.2 (referring to Ecuador's use thereof to ‘hold foreign investors accountable for environmental damage’); Monti and Nordlander (n 31) 178 (arguing for counterclaims' potential to ‘increase investors' accountability for GHG emissions’); Rudall (n 20) 458; Zheng and Calamita (n 33) 262–263.

[36]*Perenco v Ecuador* (Final Award) (n 28) para 34.

[37]*Perenco v Ecuador* (Interim Decision on the Environmental Counterclaim) (n 28) para 587.

[38]Mejía-Lemos (n 11) 1649, 1651 (recalling ‘[i]nternational law and internal law remain separated even if a norm of the latter is incorporated into the former by virtue of an [international investment agreement], in terms of both the existence and implementation of international responsibility’, and that investment treaties prevail over general international law in ISDS, given their often concurrent roles as ‘as source of particular law, specific rights and obligations, and arbitral jurisdiction’).

[39]Anning (n 23) 1286.

20500394, 2023, 2, Downloaded from https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/reel.12482 by Cochrane Sweden, Wiley Online Library on [08/03/2026]. See the Terms and Conditions (https://onlinelibrary.wiley.com/terms-and-conditions) on Wiley Online Library for rules of use; OA articles are governed by the applicable Creative Commons License

仲裁和 ISDS，特别关注其灵活性以及正在进行的 ISDS 改革可能为处理气候变化问题带来的机会。第 3 节转向 ISDS 仲裁程序中适用的法律，强调其混合性以及这一特征对于允许追究与气候变化相关的索赔和反索赔所带来的优势。第 4 节更详细地探讨了反诉规定的程序性和实质性方面。第 5 节讨论了有关履行违反环境和气候变化义务的国际责任的其他方面，特别强调 ISDS 仲裁裁决的可执行性。第六部分通过结论性总结了本文的主要发现。

2 | ISD 和 REFORT 的灵活性

《联合国宪章》规定的国际法规定的和平解决争端的方式包括“谈判、询问、调停、调停、仲裁、司法解决、诉诸区域机构或安排，或它们自己选择的其他和平方式”。[40]与任何争端一样，各国通常需要通过此类和平方式解决有关环境[41]和气候变化[42]的争端。

然而，通过国际争端解决来解决环境和气候变化问题的程度和方式可能在各个方面都受到限制。鉴于国际法中缺乏普遍的强制性管辖权，诉诸国际裁决，无论是临时的还是永久性的，总体上仍然是可选的，[43]并且范围有限，这取决于争议各方是否同意管辖权。因此，影响环境和气候变化的更广泛进程可能不会在国际争端解决的有限范围内受到充分审查。特别是，如果不建立专门处理环境或气候变化争端的国际争端解决机制，或者不将全部或主要涉及环境或气候变化问题的争端提交现有具有一般管辖权的国际法院或法庭，这些问题很可能只能得到部分解决，作为其他争端主要对象的附属物。尽管存在上述限制，国际仲裁可以发挥的作用，特别是在投资者与国家争端方面，仍然很重要，因此值得探索。

国际仲裁作为解决全部或部分与环境和环境有关的争端的一种手段可能具有非常重要的意义。

特别是气候变化，不仅因为它有能力解决涉及国家或需要适用国际法的其他方面的争端，而且还因为它有能力处理更复杂的各方和主题组合。事实上，正如常设仲裁法院所指出的，“具有自然资源、保护或环境保护成分的争议”具有“特定特征”，可以最方便地通过国际仲裁来解决。[44]此外，国际仲裁特别适合解决“混合”争议，涉及各种当事人，特别是私人当事人，例如个人、公司实体或其他国家法人。事实上，正如常设仲裁法院进一步指出的那样，国际仲裁尤其凭借其“灵活性”和当事人意思自治原则，可以充分解决一系列广泛的“涉及国家、国家控制实体、政府间组织和私人当事人的争议”。[45]

谈到 ISDS 仲裁程序及其法律监管，ISDS 改革提案可能会使 ISDS 作为处理环境和气候变化相关问题的论坛更具吸引力。

贸易法委员会第三工作组呼吁通过关于反诉的新规则，将其作为 ISDS 改革提案的一部分。[46]除其他目标外，这些提案力求在“具有不同法律性质的两个当事人：私人投资者和代表公共利益的国家”之间取得平衡。[47]为了加强对公共利益的保护，扩大允许提出反诉的法人类别被誉为授予第三方访问 ISDS 的适当方式。事实上，贸易法委员会第三工作组建议考虑“是否可以扩大被告国反诉的框架，以允许第三方针对投资者提出索赔”。[48]对于国际刑事法院来说，此类第三方可以包括东道国的“受影响社区和公民”。[49]

ISDS 改革，特别是与反诉相关的改革，包括有关投资条约实践和程序改革的要素，而且往往是相互交织的。

[40]Charter of the United Nations (adopted 26 June 51945, entered into force 24 October 1945) 1 UNTS XVI art 33.
[41]Rio Declaration on Environment and Development in ‘Report of the United Nations Conference on Environment and Development’ UN Doc A/CONF.151/26 (vol I) (12 August 1992) Principle 26.
[42]UNFCCC (n 8) art 14.
[43]Sands and MacKenzie (n 4) 308 para 11.

[44]PCA (n 5) 183 paras (i) and (ii) (namely ‘the public international law element which pertains to disputes which may involve States and utilization of natural resources and environmental protection issues’).
[45]PCA, ‘PCA Arbitration Rules 2012’ (17 December 2012) <https://docs.pca-cpa.org/2015/11/PCA-Arbitration-Rules-2012.pdf> 4, para 3(a).
[46]UNCITRAL ‘Workplan to Implement Investor-State Dispute Settlement (ISDS) Reform and Resource Requirements’ UN Doc A/CN.9/WG.III/WP.206 (21 March 2021) para 9. See also UNCITRAL (n 2) 2, para 3 (noting ‘the lack of a framework’ regulating counterclaims); Columbia Center on Sustainable Investment, ‘Climate Action Needs Investment Governance, Not Investment Protection and Arbitration’ in OECD (n 3) 75, 79, para 15 (noting proponents thereof ‘argue that they are steps in the right direction, even if they are piecemeal approaches’); McLachlan (n 6) 454–455 para 121 (discussing implications of the equality principle regarding ‘the proposed establishment of an international investment court’); Zheng and Calamita (n 33) 263 (suggesting ‘[c]ounterclaims mechanisms can be improved in future treaties … through careful drafting’); Vasani and Allen (n 12) 35.
[47]IIL (n 6) 2, preambular para 8 (noting this is one of ‘the particular characteristics of international investment disputes’).
[48]UNCITRAL (n 2) 10, para 45.
[49]ICC (n 5) 60, para 50 (discussing the IBA Model Mining Development Agreement).

在投资条约实践改革建议方面，[50]反诉在最近的争论中占据了突出地位。[51]学者认为，投资条约法改革可以考虑人权条约法，作为未来国际投资协定如何规范反诉的模板。[52]投资相关文书，从示范投资条约到最近缔结的投资条约，都采用了各种反诉方式。

一方面，一些文书明确允许被诉国提出反诉。[53]至于“大区域”文书，例如《跨太平洋伙伴关系全面进步协定》规定，“被诉国可以就诉求的事实和法律依据提出反诉”。[54]至于区域性文书，非洲的做法也值得注意。非洲联盟的泛非投资法草案是国际投资协议范本的一种形式，除了明确规定投资者有义务遵守环境立法和保护环境，以及在其活动造成任何损害时“采取合理措施尽可能恢复环境”之外，明确允许各国提出反诉。[55]在东部和南部非洲共同市场 (COMESA) 内，2007 年 COMESA 共同投资区投资协议明确允许各国主张，其中包括反诉，前提是索赔人 COMESA 投资者或投资未履行条约规定的“义务”，“包括遵守所有适用的国内措施的义务，或未采取所有合理措施减轻可能的损害”。[56]2012 年南非发展共同体 (SADC) 双边投资条约范本 (BIT) 也设想东道国提出反诉。[57]

另一方面，最近的一些文书没有提及反诉。例如，欧盟-加拿大全面经济贸易协定（CETA）中唯一明确涉及反诉的条款禁止反诉根据保险或担保合同给予投资者赔偿的理由。[58]

在程序改革方面，反诉被视为重新平衡国际投资法的关键。[59]例如，向贸易法委员会第三工作组提交的意见认为，“应允许被诉国就投资者的任何违约行为提出反诉，[以]解决现有 ISDS 机制中的不平衡问题”。[60]各国直接对 ISDS 中“反诉的可用性有限”表示担忧，[61]尽管，例如，ICSID 缔约国可以提出反诉。[62]

ISDS 仲裁庭和学者都对 ISDS 程序改革的理由和范围进行了讨论。对于根据伊斯兰合作组织 (OIC) 投资协议 (OIC 协议) 组成的 Al-Warraq 诉印度尼西亚仲裁庭，[63] 反诉是在 ISDS 中实现投资者与国家之间平衡的关键，“因为投资条约具有“固有的不对称性”。[64] 在这种情况下，可能涉及立法程序和仲裁程序。[65] Cheng 和 Calamita 认为，反诉的可用性和有效使用现有国际投资协定下的反诉可能需要这些条约缔约方在可行的情况下进行联合解释，甚至需要“修改条约中的仲裁规则和/或管辖权条款”。[66]对他们来说，“通过多边机构修改批发规则”

[50]Some have argued the rebalancing of investors and states' positions may also occur as a matter of customary international law. L Boisson de Chazournes, ‘Changes in the Balance of Rights and Obligations: Toward Investor Responsibilization’ (2017) 111 Proceedings of the ASIL Annual Meeting 53.

[51]Among proposed treaties, some have put forward a proposed treaty combining elements of sustainability and climate change. Nathalie Bernasconi-Osterwalder et al, ‘Treaty on Sustainable Investment for Climate Change Mitigation and Adaptation: Aligning International Investment Law with the Urgent Need for Climate Change Action’ (2019) 36 Journal of International Arbitration 7.

[52]Monti and Nordlander (n 31) 178.

[53]UNCITRAL (n 2) 8, para 34 (noting ‘[r]ecent investment treaties have also included provisions allowing counterclaims’).

[54]Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (adopted 8 March 2018, entered into force 30 December 2018) art 9.19(2).

[55]African Union Commission, ‘Draft Pan-African Investment Code’ AU/STC/FMEPI/EXP/18 (II) (26 March 2016) art 37.

[56]Investment Agreement for the COMESA Common Investment Area (adopted 23 May 2007) art 28(9) (providing under the aforementioned circumstances a COMESA Member State ‘may assert as a defence, counterclaim, right of set off or other similar claim’ for the aforementioned purposes).

[57]SADC Model Bilateral Investment Treaty Template with Commentary (July 2012) art 19(2).

[58]Comprehensive Economic and Trade Agreement between Canada, of the one part, and the European Union and its Member States, of the other part (adopted 30 October 2016) Document 22017A0114(01) (CETA) art 8(40).

[59]Zheng and Calamita (n 33) 263 (referring to ‘the investment treaty regime’); T Gleason, ‘Examining Host-State Counterclaims for Environmental Damage in Investor-State Dispute Settlement from Human Rights and Transnational Public Policy Perspectives’ (2021) 21 International Environmental Agreements: Politics, Law and Economics 427, 427 (noting international investment agreements' ‘asymmetric nature … can act as a barrier to counterclaims against investors using ISDS, even where an investor causes significant harm to the host-State, including environmental damage.’) In particular, the ability for ‘self-calibration’ of the existing ISDS system has been pointed out by arbitral institutions and scholars supporting incremental, primarily procedural, reforms. Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce (SCC), ‘ISDS Reform and Climate Change’ (12 March 2022) <http://sccinstitute.com/about-the-scc/news/scc-forecasts/isds-reform-and-climate-change/> (reporting on the SCC's position as observer within the UNCITRAL WGIII, proposing to ‘[t]o bring down the walls between the silos of international investment law and international climate change law’, and affirming ‘international investment agreements (IIA) hold a great potential as climate change instruments’, as ‘[t]hey could play a role to accelerate domestic ambitions’); DW Rivkin, SJ Lamb and NK Leslie, ‘The Future of Investor-State Dispute Settlement in the Energy Sector: Engaging with Climate Change, Human Rights and the Rule Of Law’ (2015) 8 Journal of World Energy Law and Business 130, 130. For a view contesting the sufficiency of procedural reforms, see DB Magraw and S Puig, ‘Greening Investor-State Dispute Settlement’ (2018) 59 Boston College Law Review 2,717, 2,734 (arguing ISDS reform within UNCITRAL WGIII has the potential to address climate change, but concluding ‘the international investment regime [problems] are deeper [than procedural problems] and should respond to bigger, more relevant issues such as climate change’).

[60]UNCITRAL (n 2) 8 para 33.

[61]C McLachlan, *The Institute of International Law's Resolution on the Equality of Parties before International Investment Tribunals: Introduction, Text and Commentaries* (Cambridge University Press 2021) 74.

[62]ICSID Convention (n 27) art 46.

[63]Agreement on Promotion, Protection and Guarantee of Investments among Member States of the Organisation of the Islamic Conference (adopted 5 June 1981, entered into force 23 September 1986) (OIC Agreement); *Hesham TM Al-Warraq v Republic of Indonesia* (Final Award) UNCITRAL (15 December 2014) 6 para 10.

[64]ibid 205, para 659 (noting ‘[c]ounterclaims are problematic in investment arbitration’).

[65]MC Porterfield, L Johnson and B Skartvedt Guven, ‘Reforming the International Investment Regime through a Framework Convention on Investment and Sustainable Development’ (UNCITRAL 2020) 5 (referring to counterclaims under heading ‘substantive’ reform).

[66]Zheng and Calamita (n 33) 263 (also referring to ‘“softer” guidance through multilateral statements of intent’).

20500394, 2023, 2, Downloaded from https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/reel.12482 by Cochrane South America, Wiley Online Library on [08/03/2026]. See the Terms and Conditions (https://onlinelibrary.wiley.com/terms-and-conditions) on Wiley Online Library for rules of use; OA articles are governed by the applicable Creative Commons License

可能需要“投资法庭”。[67]郑和卡拉米塔似乎在上述命题中混淆了具有不同法律性质的条约和仲裁规则的修改过程。尽管法律性质不同，但仲裁规则可能不需要“批量”修改。贸易法委员会同样指出，“关于提出反诉的可能性以及此类诉求可受理性的规定可以明确纳入投资条约、仲裁规则或程序改革多边文书中”，[68]与国际投资协定中的管辖权规定形成鲜明对比。然而，正如联合国国际贸易法委员会正确回顾的那样，“适用于 ISDS 的程序规则通常考虑到被申请人在诉讼期间提出反诉的可能性”。[69]

3 | ISD 的混合性和实质性义务的来源

ISDS 仲裁程序适用的法律是源自国家法律体系和国际法的原则和规则的组合，这一特征通常被称为 ISDS 的“混合性”。[70]此外，所涉及的国际法包括一般国际法和特定条约法，后者既涉及程序规则又涉及实体规则。正如新加坡上诉法院在 Swissbourgh v Lesotho 案中所指出的，“国际投资法是一种混合法律结构，独特地置于国内法和国际法以及私法和公法的十字路口”，并且基于“条约的不同寻常之处在于，这些条约的缔约国承担了可由私人个人执行的义务”，特别是通过“因涉嫌违反投资条约义务而对东道国提起诉讼”。[71]

ISDS 中适用法律的混合性引发了有关国际投资法的性质以及投资条约之外规则的使用的问题。[72]

关于 ISDS 的混合性可能对 ISDS 仲裁程序是否适合解决与环境（更具体地说是气候变化）相关问题的影响，学术界仍存在分歧。[73]

一方面，大多数作者认为外国投资对环境和气候变化的影响很大程度上是负面的，将国际投资法描述为环境保护和气候变化相关措施的障碍东道国，更不用说作为造成或加剧环境破坏和气候变化的因素了。事实上，人们常常认为，某些投资者不仅造成了环境损害，[74]而且他们还为东道国最终为解决这些投资者的行为可能造成的问题而采取的措施寻求赔偿。[75]这种负面影响还可能包括据称 ISDS 对东道国采取环境保护和减缓气候变化措施的能力产生的影响。

正如 Sands 所说，ISDS 对东道国环境保护和气候变化缓解措施的潜在影响是日益激烈的“相互竞争的社会目标之间的斗争”的核心。[76]这种影响可以在最近几起涉及东道国环境措施的 ISDS 仲裁程序中看到，例如 Rockhopper v Italy。[77]有些案件涉及东道国采取的与气候变化有些相关的措施，如 Grenada Power v格林纳达。[78]其他一些案例，同样涉及东道国采取的与气候变化相关的措施，具有更根本的含义，即这些措施所针对的特定行业或部门的投资必须永久停止运营，从而从根本上颠覆各自投资者的商业模式，[79]例如，如 RWE 诉荷兰案中所观察到的逐步淘汰燃煤电厂的规定。[80]这些 ISDS 仲裁程序引发了人们对气候变化相关问题的担忧。“监管冷淡”是一种与东道国监管其他领域相关的广泛讨论现象，特别阻碍东道国行使其监管权，特别是为了履行对其具有约束力的任何气候变化义务，并且可能在目标行业运营的所有司法管辖区中这样做。[81]

尽管上述负面影响被广泛归因于国际投资法和 ISDS，但正如 Tienhaara 指出的那样，“一个普遍的误解是，政府可以

[67]ibid.
[68]UNCITRAL (n 2) 10, para 45.
[69]ibid 8, para 34.
[70]Mejía-Lemos (n 11) 1634.
[71]*Swissbourgh Diamond Mines (Pty) Ltd and others v Kingdom of Lesotho* [2018] SGCA 81, para 1.
[72]Mejía-Lemos (n 11) 1625 (discussing the view of selected ISDS arbitral tribunals that international law is a two-tier system containing a ‘general’ system and ‘sub-systems’, a myriad of which collectively make up ISDS).
[73]The recent, still developing trend of explicitly referring to ‘climate change’ in international investment agreements is discussed in this vein. Hán (n 29) 154 (discussing a finding of the United Nations Conference on Trade and Development that, among 42 international investment agreements concluded since 2015, 15 treaties expressly refer to environmental aspects, including ‘climate change’.)
[74]Monti and Nordlander (n 31) 178 (notably greenhouse gas emissions).
[75]Calvert (n 32) 39, para 3 (arguing investors have sought ‘compensation for disruptions to investment projects that stem from their own environmental mismanagement’).
[76]Partial Dissent of Professor Philippe Sands QC, *Eco Oro Minerals Corp v Republic of Colombia* (Decision on Jurisdiction, Liability and Directions on Quantum) ICSID Case No ARB/16/41 (9 September 2021) para 1.
[77]These proceedings concern investment in the oil and gas industry. *Rockhopper Italia SpA, Rockhopper Mediterranean Ltd, and Rockhopper Exploration Plc v Italian Republic* (Decision on the Intra-EU Jurisdictional Objection) ICSID Case No ARB/17/14 (26 June 2019) 1 para 5.
[78]The *Grenada Power* tribunal dismissed Grenada's various policy-oriented arguments concerning the claimants' involvement in an entity's conduct as a ‘good corporate citizen’, essentially noting its mandate was exclusively to determine whether any contractual breaches had been committed by Grenada and what remedies should consequently be awarded to the claimant. *Grenada Private Power and WRB Enterprises Inc v Grenada* (Award) ICSID Case No ARB/17/13 (19 March 2020) 10, paras 8 and 12; and 55, para 140.
[79]K Tienhaara, ‘Regulatory Chill in a Warming World: The Threat to Climate Policy Posed by Investor-State Dispute Settlement’ (2018) 7 Transnational Environmental Law 229, 241 (observing that ‘fossil fuel corporations are faced with an existential threat to their business’).
[80]These proceedings arose out of the Netherlands's decision to prohibit the production of electricity by burning coal in 2019. *RWE AG and RWE Eemshaven Holding II BV v Kingdom of the Netherlands* (Request for Arbitration) ICSID Case No ARB/21/4 (20 January 2021) 1, para 2 (adding the dispute ‘relates to Claimants’ investments in the new coal-fired power plant Eemshaven’).
[81]K Miles, ‘Arbitrating Climate Change: Regulatory Regimes and Investor-State Disputes’ (2010) 1 Climate Law 63, 76 (referring to concerns over the impact of ISDS on ‘new environmental protection measures, including new climate change mitigation measures’); Tienhaara (n 79) 232 and 238 (observing ‘regulatory chill’ takes the form of ‘internalization chill, threat chill, and cross-border chill’).

被 ISDS 法庭强迫撤销法规”，因为“ISDS 对健康和环境监管没有直接影响”。[82]Tienhaara 的观察是准确的，因为 ISDS 仲裁法庭以及一般的国际法院和法庭通常缺乏废除或修改国家国内法范围内的国家措施的管辖权（不妨碍按照适用条约的要求适用国内法规则），因此唯一的任务是查明此类措施是否有效违反国际法义务。此外，在不存在任何排除不法性的情况下，国际法院和法庭主要需要按照国家责任法的规定宣布国际责任并命令责任方进行修复。事实上，即使在下令“司法恢复原状”的情况下也是如此。虽然司法归还可能要求“在责任国法律体系内……修改法律状况”，特别是通过“撤销、废除或修正”责任国采取的宪法、立法、行政或司法措施，但对责任国措施地位的这种改变应由该责任国在其国内法律体系内通过，而不是由下令进行此类归还的国际法院或法庭直接采取。[83]正如国际法院在阿韦纳案中所指出的那样（墨西哥诉美国），如果命令以审查或重新考虑刑事判决的形式进行司法恢复，“这种审查和重新考虑的具体方式应主要留给”责任国。[84]而且，在任何情况下，抛开管辖权限制，ISDS 仲裁庭可能倾向于认为，正如仲裁庭在 Masdar 和 Wind Cooperatief 诉西班牙一案中所指出的那样，“不应授予司法恢复……因为这样做”会给被告的立法和监管自主权带来不当负担”。[85]

另一方面，一些学者承认，国际投资法和 ISDS 可以促进环境和气候变化相关监管的有效性，同时不否认上述讨论的潜在负面环境和气候影响。[86]国际投资法和 ISDS 的这种潜在作用值得探讨，更重要的是，正如 Tienhaara 等 ISDS 批评者所承认的，以及 Schill 等 ISDS 支持者所认为的那样，国际投资法和 ISDS 本身就不一定会导致东道国对环境保护和气候变化相关监管的“监管冷淡”。[87]

这种观点的证明是，越来越频繁地依赖国际投资协议来追究东道国未能实施保护可再生能源外国投资的措施的责任，针对捷克共和国、[88]意大利[89]和西班牙提起的几起 ISDS 仲裁程序就是例证。[90]这些程序大多数是根据 ECT 启动的，占截至 2020 年 10 月所有公开的 ECT 仲裁的 60%。[91]

此外，这一立场得到了投资条约实践和相关文书的趋势的证实，正如最近的投资协定范本中的规定所表明的那样，重申了各方根据不直接管辖外国投资的各种多边协定所承担的义务，特别是《巴黎协定》。[92]同样，最近的投资条约明确重申了东道国基于环境理由进行监管的权利[93]，并特别要求投资者遵守对东道国具有约束力的环境义务国家。[94]这些明确的规定增加了传统和当代投资条约实践试图排除外国投资潜在环境负面影响的其他方式。事实上，各种投资条约都禁止东道国通过减损、减少或免除环境要求等倒退措施鼓励外国直接投资，正如《北美自由贸易协定》(NAFTA)[95]以及取代 NAFTA 的美利坚合众国、墨西哥合众国和加拿大之间的协定[96]中的规定所表明的那样。

因此，根据上述思想流派，ISDS 不应因为必然不适合解决非投资问题而被抛弃。

[82]Tienhaara (n 79) 233.

[83]International Law Commission, ‘Draft articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, with commentaries’ (2001) II(2) Yearbook of the International Law Commission 31, 97 para 5. See also A Dimopoulos, ‘Climate Change and Investor-State Dispute Settlement: Identifying the Linkages’ in P Delimatsis (ed), *Research Handbook on Climate Change and Trade Law* (Edward Elgar 2016) 415 (arguing ISDS arbitral tribunals cannot pose any true ‘threat’ to climate change measures, since their jurisdiction is limited to finding whether investment treaty breaches have been committed).

[84]*Avena and Other Mexican Nationals (Mexico v United States Of America)* (Judgment) [2004] ICJ Rep 12, para 131 (adding ‘this freedom in the choice of means for such review and reconsideration is not without qualification’, since it must be exercised in light of the particular nature of the breach in question).

[85]*Masdar Solar & Wind Cooperatief UA v Kingdom of Spain* (Award) ICSID Case No ARB/14/1 (16 May 2018) 172, paras 559–560 (adding juridical restitution ‘would potentially benefit numerous parties not protected by the ECT’ and that ‘[s]imilarly situated tribunals have denied restitution of regulatory regimes’).

[86]C Crépet Daigremont, ‘Les arguments relatifs au réchauffement climatique dans l'arbitrage d'investissement’ (2020) 3 Revue de Droit International d'Assas 89, 91, fn 10.

[87]SW Schill, ‘Do Investment Treaties Chill Unilateral State Regulation to Mitigate Climate Change?’ (2007) 24 Journal of International Arbitration 469.

[88]See, e.g., *ICW Europe Investments Limited v Czech Republic* (Award) PCA Case No 2014-22 (15 May 2019).

[89]See, e.g., *The PV Investors v Spain* (Final Award) PCA Case No 2012-14 (28 February 2020).

[90]See, e.g., *Eskosol SpA in liquidazione v Italian Republic* (Award) ICSID Case No. ARB/15/50 (4 September 2020).

[91]ECT Secretariat, ‘Even More Renewable Energy Investors Rely on Treaty Protection: Updated Statistics of Investment Arbitration Cases under the Energy Charter Treaty’ (ECT Secretariat, 12 October 2020) <https://www.energycharter.org/media/news/article/even-more-renewable-energy-investors-rely-on-treaty-protection-updated-statistics-of-investment-arb/>.

[92]Netherlands Model BIT (22 March 2019) art 6.6.

[93]Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Singapore on the Promotion and Protection of Investments (adopted 11 October 2018, entered into force 9 March 2021) art 11(1) (listing a set of ‘legitimate policy objectives’).

[94]Reciprocal Investment Promotion and Protection Agreement between the Government of the Kingdom of Morocco and the Government of the Federal Republic of Nigeria (adopted 3 December 2016) art 18(4) (providing ‘[i]nvestors and investments shall not manage or operate the investments in a manner that circumvents international environmental, labour and human rights obligations to which the host state and/or home state are Parties’).

[95]North American Free Trade Agreement (adopted 17 December 1992, entered into force 1 January 1994) 32 ILM 289 and 605 (1993) art 1,114(2) (recalling ‘[t]he Parties recognize that it is inappropriate to encourage investment by relaxing … environmental measures’).

[96]Agreement between the United States of America, the United Mexican States, and Canada (adopted 30 November 2018, entered into force 1 July 2020) art 24.4.3 (noting ‘the Parties recognize that it is inappropriate to encourage trade or investment by weakening or reducing the protection afforded in their respective environmental laws’).

20500394, 2023, 2, Downloaded from https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/reel.12482 by Cochrane South America, Wiley Online Library on [08/03/2026]. See the Terms and Conditions (https://onlinelibrary.wiley.com/terms-and-conditions) on Wiley Online Library for rules of use; OA articles are governed by the applicable Creative Commons License

[97]例如，投资者可以质疑东道国的措施，指控其在保护环境方面的不足，[98]如 Allard 诉巴巴多斯案所示。[99]此外，国际投资协议还可以以其他方式使环境法生效。例如，与东道国未能保护环境影响投资者的结论相反，仲裁庭可能会发现，如果一项违反东道国环境法的投资不属于适用投资协议下投资的定义范围，仲裁庭就缺乏管辖权，如 Cortec 诉肯尼亚案所示。[100]同样，环境法也可能在被诉国以违反环境法为由提出反诉的管辖权裁决中生效。[101]从这个意义上说，反诉在解决气候变化相关问题的各种拟议方式中占据显着地位，[102]通常是“协调投资与非投资问题”。[103]事实上，ISDS 仲裁程序中与气候变化相关的反诉被描述为避免气候变化法律与外国投资法律之间不一致的一种手段。[104]

学术界还研究了国际投资协议之外的反诉规则的相关性，无论是国内法还是国际法。正如 IIL 所指出的，“仲裁庭可以认为反诉是可受理的，无论该反诉是基于国际法还是东道国法律，前提是”除其他外，反诉“涉及能够提交仲裁的标的物”。[105]

如上所述，反诉可以以东道国国内法规定的义务为基础。因此，在伯灵顿案中，厄瓜多尔关于环境严格责任的法律支持了仲裁庭的裁决，要求原告投资者对环境损害负责。[106]在佩伦科案中，仲裁庭同样适用了厄瓜多尔环境法并提及了《里约宣言》，并指出了后者对前者的影响。[107]鲁德尔提到了非国际法规则可以作为追究投资人责任的基础的各种方式。通过 ISDS 仲裁程序负责的人，包括“通过国际投资协议的合法性要求或适用法律条款以及系统一体化原则而变得国际化的国内法或合同义务”。[108]根据联合国国际贸易法委员会的规定，东道国指控不遵守投资者的国内法“很少在基于条约的 ISDS 仲裁程序中提出反诉。[109]然而，正如 Alexandrov 指出的那样，不遵守合法性要求虽然“通常被援引为抗辩”，但“如果国家因投资者在投资中的非法行为而遭受损害，则可以将不遵守合法性要求作为反诉”。[110]

一些作者还讨论了反诉依赖于投资条约之外的国际法规则，特别是国际人权法规则的可能性。[111]除了为未来的气候变化相关诉讼提供范例之外，[112]人权法可以说与气候变化相关的反诉直接相关。正如海牙地方法院在 Milieudefensie 诉 Shell 案的裁决中所体现的那样，这种直接联系可以说存在于人权法的解释作用之中，它支撑着投资者的特定气候变化义务，[113]原则上如果缺乏这种联系，东道国就无法对投资者提出与气候变化相关的反诉。[114]此外，投资者基于人权法的气候变化义务可能会在 ISDS 中援引。[115]鉴于在 Urbaser 诉阿根廷法庭的裁决中，人权法更有可能成为东道国针对投资者提出与气候变化相关的反诉的法律依据。[116]

然而，投资条约之外的规则的适用仍然存在争议。例如，瓦迪认为 ISDS 不是“执行其他条约制度的工具”。[117]ISDS 仲裁庭根据东道国国内法的一般规则驳回东道国的反诉，也表达了类似的担忧。值得注意的是，萨卢卡诉捷克共和国仲裁庭拒绝承认关于与主要索赔缺乏“共同起源、相同来源和操作统一性”的“义务”的反诉。[118]如果东道国的国内法院对支撑此类反诉的东道国国内法规则拥有专属管辖权，则反诉也会失败，导致仲裁庭发现自己缺乏对此类国内法规则进行裁决的管辖权，或者以其他方式拒绝受理该反诉。行使管辖权。 Paushok 诉蒙古案就是一个例子，在该案中，仲裁庭质疑

[97]Rudall (n 20) 468.
[98]Hán (n 29) 156.
[99]*Peter A Allard v Barbados* (Award) PCA Case 2012-06 (27 June 2016), discussed in Crépet Daigremont (n 86) 91, fn 10.
[100]*Cortec Mining Kenya Limited, Cortec Limited and Stirling Capital Limited v Kenya* (Award) ICSID Case No ARB/15/29 (22 October 2018) (applying the Kenya-United Kingdom bilateral investment treaty).
[101]Crépet Daigremont (n 86) 91.
[102]Monti and Nordlander (n 31) 176 (referring to ‘counterclaims by host States against investors based on climate change obligations’).
[103]Rudall (n 20) 470 (referring to ‘the use of counterclaims’, among others).
[104]Monti and Nordlander (n 31) 178 (arguing climate change-related counterclaims are an ‘option to strengthen the consistency between’ the aforementioned bodies of law).
[105]IIL (n 6) 3, art 2(1).
[106]Rudall (n 20) 465.
[107]*Perenco v Ecuador* (Final Award) (n 28) para 331.
[108]Rudall (n 20) 467 (referring to ‘avenues’ for ensuring ‘corporate actors’ be held responsible for conduct breaching ‘international human rights or environmental standards’).
[109]UNCITRAL (n 2) 8, para 35.
[110]McLachlan (n 6) 568.
[111]Monti and Nordlander (n 31) 176 (adding ‘human rights law can serve as an important tool to contribute to the greening of investment treaties’).
[112]ibid 178 (arguing, based on the decision in *Milieudefensie v Shell*, that ‘human rights-based climate litigation … send [sic] encouraging signals’).
[113]ibid (referring to the *Milieudefensie v Shell* decision's reliance on ‘human rights arguments as interpretative aid, that specific [greenhouse gas] emissions targets can also be imposed on corporate actors’).
[114]ibid (arguing the absence of rules requiring investors to limit [greenhouse gas] emissions implies climate change-related counterclaims remain thus ‘primarily exploratory at present’).
[115]ibid (arguing any eventual ‘human rights jurisprudence that private investors have specific obligations with regard to climate change mitigation’ could be, alongside ‘similar outcomes also be transposed into international investment disputes’).
[116]ibid (noting the *Urbaser v Argentina* tribunal ‘admitted a counterclaim by the State, based on the investor's human rights responsibilities’, and arguing it would be ‘important to expand the possibility for States to invoke investors’ human rights obligations in their counterclaims’).
[117]V Vadi, ‘Beyond Known Worlds: Climate Change Governance by Arbitral Tribunals?’ (2015) 48 Vanderbilt Law Review 1285, 1351 (adding ‘this was not the intention of its founders’ and ‘could raise more legitimacy concerns than it helps to solve’).
[118]*Saluka Investments BV v Czech Republic* (Decision on Jurisdiction over the Czech Republic's Counterclaim) UNCITRAL (2004) para 79.

20500394, 2023, 2, Downloaded from https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/reel.12482 by Cornell Law Library, Wiley Online Library on [08/03/2026]. See the Terms and Conditions (https://onlinelibrary.wiley.com/terms-and-conditions) on Wiley Online Library for rules of use; OA articles are governed by the applicable Creative Commons License

仲裁庭根据国内法做出裁决的适当性。[119]麦克拉克伦认为，尽管萨卢卡法庭和保绍克法庭持有不同观点，但伯灵顿法庭和佩伦科法庭“说明了国际仲裁法庭有能力根据国内宪法原则审议和裁决索赔要求”。[120]

4 | 乌拉尔地区的程序和反诉索赔的实质性方面

反诉的使用有实质性和程序性方面的问题，需要对概念进行澄清，特别是从大多数现有国际投资协定的单向特征来看。在这方面，Al-Warraq 仲裁庭赞赏地引用了克劳福德的观点，即仲裁庭“应该能够审理根据投资合同产生的密切相关的投资反诉”，因为“否则，条约必须遵守的格言只能朝一个方向运作”。[121]这一说法正确地回顾了实体规则的实际运作在实践中与程序手段密不可分。落实这些实质性规则所产生的权利和义务。然而，上述说法也含糊不清，因为它可能被理解为暗示条约必须遵守充分支持国际投资协定单向性的实质性和程序性方面。

程序方面的法律基础仍然不同。[122]事实上，在处理大多数投资协议的单向性时，条约下的实质性标准不得与该条约下有关争端解决的程序机制混为一谈。相反，与程序有更直接联系的一般法律原则，例如当事人平等原则，可以作为使用反诉的基础。正如 IIL 所指出的，“被申请人提出法庭可受理的反诉的能力确保了双方的程序平等”。[123]事实上，正如 IIL 所指出的，争议各方平等原则是“适用于争议当事人的一般法律原则”。[124]这一原则作为主要程序性一般法律原则的性质，并不影响条约必须遵守作为支撑仲裁庭管辖权来源原则的作用，仲裁庭通常采取仲裁协议的形式，也不影响当事人平等的性质，这是人权法规定的一项实质性权利。[125]除了上述原则外，还有其他程序性原则和原则反诉可能产生影响的方面。正如贸易法委员会指出的那样，“允许同一仲裁庭在一组程序中对反诉与初始请求一起审理，可以提高程序效率”。[126]贸易法委员会补充说，任何未来的反诉监管“框架”都应旨在“对程序的持续时间和成本产生积极影响”，以及其他“程序问题”。[127]

程序性规则和实质性规则的合并似乎支持了反诉是实质性权利和义务的来源这一观点。例如，布瓦松·德·查佐尔内斯 (Boisson de Chazournes) 的主张“反诉有可能吸收环境义务并将其纳入争议解决”[128]，必须予以限定，以澄清反诉本身并不是实质性权利和义务的来源，而是一种程序手段，使任何适用的施加这些环境义务的法律规则生效。这种混淆还可能导致责任的存在与援引责任的法律能力相混淆。例如，卡尔弗特提到“单方责任原则”，暗示这是“外国投资者有能力让国家对所造成的损害负责但政府不能起诉外国投资者的原则”。[129]在这一点上，阿斯特里蒂同样考虑了“允许国际和国内环境义务介入投资争端”的“反诉”的可能性，正确地将其描述为“合并的程序手段”。[130]反诉的程序性源于当事人平等原则的含义之一，正如 IIL 所指出的那样，它发生在“程序层面”。[131]从反诉的程序性来看，人们对其性质得出了更大的含义，尽管没有提供令人信服的理由。例如，虽然允许反诉可能被正确地描述为在 ISDS 内实现投资者和国家之间平衡的一种手段，但尚不清楚如何如 McLachlan 所言，“反诉也可以说是在宪法方面促进当事人的平等”。[132]

[119] *Paushok v Mongolia* (Award) UNCITRAL (2011).
[120] McLachlan (n 6) 480–481, para 211.
[121] J Crawford, ‘Treaty and Contract in investment Arbitration’, The 22nd Freshfields Lecture on International Arbitration (2007) 17, quoted in *Al-Warraq v Indonesia* (Final Award) (n 63) 206, para 659.
[122] As Rudall notes, ‘[t]he application of … substantive standards … requires certain procedural mechanisms’. Rudall (n 20) 458 (further recalling ‘classically, dispute resolution under investment treaties envisages that an investor may bring a claim against a state, but not vice versa’).
[123] IIL (n 6) 6, art 6(1). That that principle's operation be ensured by counterclaims does not necessarily imply or presuppose the latter is ‘required’ by the former. As IIL member J Crawford noted, ‘the procedural principle of equality of the parties does not require that the respondent state be able to bring counterclaims’. McLachlan (n 6) 544. However, IIL member P D'Argent observed, ‘[e]quality of the parties also requires that claimant is presumed to accept to face a counterclaim once it begins proceedings’. McLachlan (n 6) 569–570. In the opinion of IIL member G Gaja, who commented on *Saluka v Czech Republic*, while ‘[t]he interpretation to the effect that consent to jurisdiction over counterclaims is implied is not necessarily based on the principle of equality, but that principle may be invoked in order to reinforce it’. McLachlan (n 6) 570. According to IIL member V Mikulka, the principle's actual operation rests not so much on the ‘ability’ to submit counterclaims as on ‘the factual existence or non-existence of such counterclaims’. McLachlan (n 6) 572.
[124] IIL (n 6) 1, preambular para 2.
[125] ibid 1, preambular para 3 (observing ‘the equality of the parties is also a fundamental human right recognised by Article 10 of the Universal Declaration of Human Rights of 1948 and Article 14(1) of the International Covenant on Civil and Political Rights of 1966’).
[126] UNCITRAL (n 2) 8, para 34 (‘and may avoid multiple proceedings in different forums involving the same parties’).
[127] UNCITRAL (n 2) 9 para 38.
[128] L Boisson de Chazournes, ‘Environmental Protection and Investment Arbitration: Yin and Yang?’ (2017) 10 Anuario Colombiano de Derecho Internacional 371, 392.
[129] Calvert (n 32) 39, para 3 (arguing ‘[r]ebalancing investment treaty law requires eliminating the single-party liability’).
[130] A Asteriti, ‘Environmental law in investment arbitration: procedural means of incorporation’ (2015) 16 Journal of World Investment and Trade 248, 248.
[131] McLachlan (n 6) 420, para 6 (italics omitted).
[132] ibid 474, para 186.

上述程序性和实质性方面的独立性也可以通过权利来源在提出反诉时的运作方式得到证明。提出反请求的权利来源独立于原请求，仲裁庭对反请求的管辖权也独立于原请求。事实上，正如 IIL 所指出的，“仲裁庭对反诉是否具有管辖权并不取决于被诉人援引与原告在其主张中所依赖的管辖权相同的管辖权理由”。[133]反诉和主诉的管辖权来源之间的这种独立性在以下命题中得到了进一步观察：正如 IIL 所指出的，仲裁庭对反诉的管辖权不受“争议范围的限制”正如原告在仲裁请求中所阐述的那样”。[134]事实上，正如 McLachlan 回忆的那样，反诉的提出“源于仲裁协议是自主的、与其适用的实质性义务相分离的一般原则”。[135]它不仅与“实质性义务”相分离，而且也与规定此类义务及其各自正式来源的规则相分离。事实上，正如麦克拉克伦还回顾的那样，“争端解决条款与包含该条款的投资条约的实质性条款是分开的”。[136]而且，正如 d'Argent 在尼加拉瓜诉哥伦比亚一案中指出的那样，一旦诉讼程序开始，仲裁庭拥有管辖权的反诉就可以继续进行，“无论为索赔和反诉提供管辖权的文书后来是否终止”。[137]

构成反诉基础的实质性权利和义务的来源也可以独立于主诉的来源。例如，IIL 指出，并不要求“反诉必须基于原告主张的同一法律文书或诉因”。[138]特别是，正如 IIL 所规定，“仲裁庭可能认为反诉是可受理的，无论它是基于国际法还是东道国法律”，即使原告援引的法律文书必然是投资协议。[139]上述命题意味着，正如 McLachlan 所说，“仲裁庭可以扩展到以条约具体实质性条款之外的合法权利为基础的索赔，无论是东道国法律还是国际法（前提是索赔始终有法律依据）。[140]此外，这种广泛的管辖范围符合国际投资法的混合性：正如麦克拉克伦指出的那样，这种混合性使 ISDS 仲裁庭能够“同时适用东道国法和国际法来裁决争端”。[141]

[133]IIL (n 6) 6, art 6(3).
[134]ibid.
[135]McLachlan (n 6) 477, para 196.
[136]ibid 473, para 181.
[137]*Alleged Violations of Sovereign Rights and Maritime Spaces in the Caribbean Sea (Nicaragua v Colombia)* (Order) [2017] ICJ Rep 289, discussed by IIL member D'Argent in McLachlan (n 6) 570.
[138]IIL (n 6) 7, art 6(5).
[139]ibid (provided, among others, ‘that it … concerns a subject matter that is capable of submission to arbitration’).
[140]McLachlan (n 6) 477, para 197.
[141]ibid.

实质内容和程序之间的区别并不妨碍它们的结合对于法律规则的有效运作是不可或缺的。特别是，这是 ISDS 可以预测的。正如 Boisson de Chazournes 所指出的，“国际法院和法庭（包括投资法庭）的程序手段……包括……反诉”。[142]值得注意的是，反诉允许执行“针对投资者的义务”并确保对投资者造成的损害给予赔偿。[143]此外，这种区别可能与与投资不直接相关但可能包含在现有或拟议投资协议中的实体规则相关。贸易法委员会第三工作组建议“制定关于投资者义务的规定，作为国家反诉的基础”，并且“可能涉及保护人权和环境、遵守国内法、反腐败措施和促进可持续发展”。[144]正如 Rudall 所观察到的，“[c]结合明确的实质性规定[，]……程序机制……为追究公司违反非投资行为的责任提供了更坚实的法律基础。[145]同样，正如 Boisson de Chazournes 指出的那样，“反诉允许 ISDS 仲裁庭‘分析投资者’针对国家非经济权利（包括保护环境的权利）的行为”。[146]

5 | 国际社会响应的实施以及可持续发展条约的强制力

关于 ISDS 的适用性，特别是使用反诉来解决涉及气候变化相关要素的争端，还存在其他问题。有些问题涉及对投资者直接索赔的可能性。其他问题涉及东道国诉诸 ISDS 的明显优势和限制，无论是通过索赔还是反索赔，特别是在 ISDS 仲裁裁决的可执行性所提供的机会方面。考虑这些问题需要重新审视反诉的管辖权和可受理性条件。

提出反诉需要满足管辖权和受理条件，这是有关东道国反诉可行性争论的核心。事实上，东道国作为被申请人在众所周知的 ISDS 仲裁程序中提出的大多数反诉均未能满足这些条件，迄今为止，成功的反诉已得到了东道国的明确同意。

[142]Boisson de Chazournes (n 128) 389 (noting they are ‘crucial for ensuring environmental protection’ and also referring to ‘the resort to experts … and *res judicata*.’)
[143]ibid 392.
[144]UNCITRAL (n 2) 9, para 41.
[145]Rudall (n 20) 458.
[146]Boisson de Chazournes (n 128) 394 (commenting on *Perenco* and *Burlington*.)

争议各方，[147] 正如 Aven 诉哥斯达黎加一案所指出的。[148] 因此，对这些条件进行评论是有意义的。

就管辖权而言，如果按照 IIL 的规定，“根据被申请人援引的同意书，如果该反诉被作为主要请求提出，则仲裁庭对该反诉拥有管辖权”，那么被申请人的反诉就属于仲裁庭的管辖范围。[149]在 ICSID 仲裁程序的特殊情况下，反诉还必须满足属于 ICSID 中心管辖范围的要求。[150]在进行 ISDS 仲裁程序的情况下根据 2010 年修订的《联合国国际贸易法委员会仲裁规则》，“被申请人可以提出反诉……前提是仲裁庭对其具有管辖权”。[151]这一修订是为了适应商业仲裁和投资仲裁而特意采用的。[152]

仲裁管辖权的来源一般体现在仲裁协议中，表明同意将争议提交仲裁。仲裁协议虽然与包含它的主协议分开，但其范围通常由该主协议中规定的条款决定。[153]国际投资协议中的争端解决条款的范围通常是基于条约的 ISDS 仲裁程序，“影响国家可以提出反诉的程度”。[154]对于 McLachlan 来说，这些条约条款往往分为两类，即“一般双边”和“单向”[155]就其属人和属事的运作范围而言，“一般双边”条款允许东道国或投资者在不同程度的细节上就它们之间的任何法律纠纷提出索赔，而“单向”条款“在这两方面都受到限制”。[156]这些限制在不忽视实质性和程序性方面之间的区别的情况下，说明了投资者的实质性法律地位如何影响其程序性法律地位。正如亚历山德罗夫指出的，当涉及“单向”条款时，“反诉可能超出了授予管辖权的条款的范围”，因为“投资者无法违反其不承担任何义务的条约”。[157]

至于可否受理，在 IIL 看来，反诉必须“直接源于投资标的”。[158]根据 IIL，这种“联系充分性的要求……不要求反诉以原告主张的同一法律文书或诉讼理由为基础”。[159]

上述讨论的假设是，东道国通常会在国际范围内，特别是在 ISDS 仲裁程序的背景下，通过针对外国投资者的反诉，在国际层面上寻求救济，特别是在 ISDS 仲裁程序中，前提是满足上述反诉的管辖权和可受理性条件。然而，这样的选择并不是理所当然的。正如联合国国际贸易法委员会所指出的，“被诉国在 ISDS 中提出的反诉……不应排除在国内法院向投资者提出索赔的可能性，只要这样做有法律依据”。[160]

事实上，各国可以决定诉诸本国法院来追究投资者的责任。根据联合国国际贸易法委员会 (UNCITRAL) 的规定，他们确实这样做了，特别是当他们的主张涉及国内法而不是国际法时。[161]正如国际法协会所指出的，国家拥有“主权权力，可以执行自己的法律，并在自己的法院上裁决针对投资者违反其法律的索赔”。[162]虽然这种权力不会延伸至追究投资者涉嫌违反国际法义务的责任（如果有的话），[163]提供了主要来源投资者的义务是东道国的法律，因此行使这一主权权力是不可放弃的。事实上，正如《国际投资法》所补充的，虽然一国“同样有权向根据国际法设立的法庭提出与投资有关的索赔”[164]，但它“没有义务向[此类]法庭提交针对投资者的索赔，除非它表示同意并选择这样做”。[165]选择诉诸国内法院的其他方面涉及国际投资法可能对该选择产生的间接影响。事实上，正如郑和卡拉米塔所观察到的，国内法院的裁决可以构成根据国际投资条约提出索赔的基础。[166]在这方面，他们补充道，“投资者.....可以通过利用投资条约寻求推翻关于环境损害责任的国内判决”。[167]然而，如上所述，只要国际法院和法庭没有能力“推翻”一国机关根据该国国内法通过的决定，就认为 ISDS 为投资者提供这种补救措施是不准确的。当然，在因东道国司法机关违反投资协议而进行的 ISDS 仲裁程序中可能会指明赔偿措施，特别是赔偿的形式，这可能是一国决定不诉诸本国法院为投资者造成的损害寻求救济的一个因素。

[147]Namely, in *Burlington* and *Perenco*. McLachlan (n 6) 475, para 188, fn 232 (noting in these two cases ‘the Parties consented to the Tribunal's jurisdiction over the counterclaim by *compromis*’).
[148]*David Aven* et al *v Costa Rica* (Final Award) Case No UNCT/15/3 (18 September 2018) para 736 (stating ‘[m]ost international investment tribunals have not recognized jurisdiction over the counterclaims introduced before them in the absence of an explicit agreement between the parties to submit the counterclaim to the arbitral tribunal’).
[149]IIL (n 6) 6, art 6(3).
[150]ICSID Convention (n 27) art 25(1), discussed in IIL (n 6) 6, art 6(4).
[151]UNGA ‘UNCITRAL Arbitration Rules (as revised in 2010)’ UN Doc A/RES/65/22 (6 December 2010) art 21(3).
[152]McLachlan (n 6) 476, para 192.
[153]Mejía-Lemos (n 11) 1617.
[154]McLachlan (n 6) 474, para 183.
[155]ibid 473, para 181.
[156]ibid 473–474, paras 182–183.
[157]ibid 568–569.
[158]IIL (n 6) 6, art 6(2).
[159]ibid 7, art 6(5).
[160]UNCITRAL (n 2) 7–8, para 32.
[161]UNCITRAL (n 2) 8, para 35 (noting ‘States have resorted to domestic courts to seek affirmative relief’).
[162]IIL (n 6) 3, art 1(2).
[163]*Aven v Costa Rica* (Final Award) (n 148) paras 737 and 743 (noting ‘the enforcement of environmental law is primarily [entrusted] to the States, but it cannot be admitted that that a foreign investor could not be subject to international law obligations’, yet concluding the provisions at issue ‘do not … impose any affirmative obligation upon investors’).
[164]ibid 3, art 2(1).
[165]ibid 3 art 2(2).
[166]Zheng and Calamita (n 33) 263.
[167]ibid.

20500394, 2023, 2, Downloaded from https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/reel.12482 by Cochrane Sweden, Wiley Online Library on [08/03/2026]. See the Terms and Conditions (https://onlinelibrary.wiley.com/terms-and-conditions) on Wiley Online Library for rules of use; OA articles are governed by the applicable Creative Commons License

或者，各国可以在 ISDS 程序中直接向投资者提出索赔，这可能会扭转其作为被告的典型地位。《ICSID 公约》允许缔约国或其国民在 ICSID 仲裁程序中提出索赔，[168] 据报道，ICSID 缔约国尚未利用这种可能性。[169] 各种国际投资协定也提供了这种可能性。例如，根据《伊斯兰会议组织协议》，“各方均有权诉诸仲裁法庭对争议作出最终裁决”。[170]根据 Al-Warraq 仲裁庭的说法，“《伊斯兰会议组织协议》……[授权]缔约国提出反诉”，而且还直接“设想缔约国提出主张”，可以说是考虑了“缔约国作为申请人对投资者提起仲裁”的可能性。[171]事实上，对于 Al-Warraq 仲裁庭来说，“一方当事人可以通过自行启动仲裁或在另一方先启动仲裁的情况下提出反诉来行使‘诉诸仲裁的权利’”。[172]

上述属人仲裁管辖权范围的扩大只有在其属事管辖权范围适当宽广的情况下才能完全有效，正如《国际劳工法》“一般双边”条款概念所表达的那样。例如，阿根廷-西班牙双边投资协定与伊斯兰会议组织协定一样，不仅限制作为投资者提出索赔的能力，也不限制根据该协定提交仲裁的争议标的，特别是因为违反该双边投资协定不一定会引起争议。[173]这与 2008 年西非国家经济共同体 (西非经共体) 投资补充法形成鲜明对比，其中“东道成员国可以针对……提出反诉”[174] 除了足够广泛的属人管辖权之外，仲裁庭通常还需要扩大属事管辖权范围，以对东道国的请求或反请求主张管辖权，因为国家通常不是大多数国际投资协定规定的实质性保护的受益人或持有人，因此往往无法将其请求或反请求基于违反其规定。这似乎是基于条约的 ISDS 普遍存在的一个特征。正如 Boisson de Chazournes 指出的那样，基于条约而不是基于合同，ISDS 使“权利和义务的平衡……朝着投资者保护的方向倾斜”。[175]相反，投资合同一直被依赖于引入东道国反诉，例如，作为厄瓜多尔在伯灵顿和佩伦科案中成功反诉的来源。[176]

某些临时设立的国际法院和法庭缺乏永久地位，是国际争端解决的一个普遍特征，[177]，尤其是 ISDS，[178] 这对反诉有一定影响。事实上，就一般环境和气候变化相关争议而言，Sands 和 MacKenzie 认为，就解决此类争议的体制机制而言，“对争议解决程序缺乏制度支持也被认为是一个差距”。[179]虽然由仲裁机构管理的特设仲裁庭从这些机构提供的支持中永久受益，但与 Sands 和 MacKenzie 的一般声明可能暗示的相反，众所周知，仲裁庭的短暂性仍然会带来一些限制。特别是，这种限制在某种程度上也适用于 ISDS 中反诉的使用。例如，Perenco 仲裁庭拒绝下令将厄瓜多尔获得的环境损害赔偿金支付给环境修复基金，尽管双方已达成一致，[180] 理由是确保遵守这样的命令“不符合仲裁庭的职责”，因为一旦发布最终裁决，“仲裁庭就具有职权”。[181]这将为以下观点提供支持： Vadi 认为，“由于其职权有限，仲裁法庭并不是裁决气候相关争议的最佳场所”，[182]这与具有永久地位的国际法院和法庭不同。然而，拟议建立常设国际法院和法庭来进行 ISDS 程序的主要依据是限制此类常设 ISDS 法院和法庭对投资者因违反相应国际投资协议而提出索赔的属事管辖权和属人管辖范围的条款。[183]事实上，CETA 集中体现了拟议常设 ISDS 法院和法庭管辖权的这一限制，因为它包含一个典型的“单向”条款，即“CETA 限制其争议解决程序的使用”投资者因违反 CETA 规定的义务而提出索赔，“如果投资者声称因所指控的违约行为而遭受损失或损害”。[184]因此，至少目前设想的永久性 ISDS 法院和法庭似乎不太可能

[168]ICSID Convention (n 27) art 36(1).
[169]McLachlan (n 6) 445 para 87 (footnotes omitted).
[170]OIC Agreement (n 63) art 17(2)(a).
[171]*Al-Warraq v Indonesia* (Final Award) (n 63) para 660.
[172]ibid 207, para 661 (pursuant to OIC Agreement (n 63) art 17(2)(a)).
[173]S Vezzani, ‘Diritto internazionale degli investimenti e diritto all'acqua: il caso dell'Argentina’ in LF Pastorino (ed), *Las formas de la naturaleza y sus formas de regulación* (Ediciones Cooperativas 2018) 177, 187 (discussing the content of the Argentina-Spain BIT art X and noting under that provision such disputes need not be ‘controversie … relative ad asserite violazioni del BIT stesso’).
[174]Supplementary Act Adopting Community Rules on Investment and the Modalities for their Implementation with ECOWAS (adopted 19 December 2008, entered into force 19 January 2009) ECOWAS Doc A/SA.3/12/08 art 18(5).
[175]McLachlan (n 6) 544.
[176]Calvert (n 32) 39, para 3.2 (noting this is due to the paucity of provisions in international investment agreements allowing for claims against investors).
[177]Indeed, a tendency in multilateral environmental agreements, towards preferring ad hoc dispute settlement over resort to permanent dispute settlement institutions has been observed. A Kiss, ‘Le règlement des différends dans les conventions multilatérales relatives à la protection de l'environnement’ in RJ Dupuy (ed), *The Settlement of Disputes on the New Natural Resources* (Brill 1993) 119, 122–123.
[178]IIL (n 6) 2, preambular para 9 (considering ‘the position of both kinds of arbitral tribunals, whether are appointed ad hoc … (‘arbitral tribunal’) or any standing tribunal … (‘permanent tribunal’)’ present or future).
[179]Sands and MacKenzie (n 4) 338, para 62.
[180]*Perenco v Ecuador* (Final Award) (n 28) paras 900–901.
[181]ibid para 902.
[182]Vadi (n 117) 1351 (‘and their uneven consideration of environmental concerns in the past’).
[183]McLachlan (n 6) 473, para 182 (noting ‘current forms of dispute settlement clauses in those treaties or drafts that contemplate the establishment of a standing investment tribunal are one-way clauses’).
[184]CETA (n 58) art 8(18), discussed in McLachlan (n 6) 473, para 182.

20500394, 2023, 2, Downloaded from https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/reel.12482 by Cochrane South University, Wiley Online Library on [08/03/2026]. See the Terms and Conditions (https://onlinelibrary.wiley.com/terms-and-conditions) on Wiley Online Library for rules of use; OA articles are governed by the applicable Creative Commons License

充分解决大多数现有 ISDS 仲裁庭的临时性质所带来的挑战。

即使依赖国内法，诉诸国际仲裁而不是国内诉讼的最重要原因是仲裁裁决在适用于 ISDS 仲裁程序的各种制度下的可执行性。正如郑和卡拉米塔所指出的那样，国际仲裁即使不是“唯一可用”的，也是一个“重要”的援引投资者环境损害责任的论坛。[185]事实上，正如他们所解释的，国内法院可能会以不方便法院原则或遵守基于合同的仲裁协议为由拒绝行使管辖权。[186]在他们看来，国内法院无法获得执行机会，这将证明关注“反诉，特别是在涉及环境损害指控的案件中”是合理的。伤害”。[187]

ISDS 仲裁裁决可执行性的重要性，特别是其与东道国可用的程序手段相关的相关性，在 ICSID 公约的筹备工作中得到了重申。事实上，布罗奇斯指出，《ICSID 公约》中关于可执行性的条款规定了裁决在其他缔约国领土上的可执行性，“主要考虑到东道国的需要”。[188]根据麦克拉克伦的说法，这种有意强调东道国可执行机制的可用性表明，ICSID 公约“可能是不对称的，但至少在其设计上并非单方面的”。[189]

此外，正如麦克拉克伦所说，东道国选择诉诸国际仲裁而不是本国法院，“本身可能会产生重大的主权影响”，特别是暗示“对其本国法院缺乏信心”，[190]但这种选择“仍然有充分的实际理由”。[191]这些原因不仅包括“外国投资者（不同于其当地投资工具）很可能在东道国管辖范围内没有存在”[192]但更关键的是，“ICSID 仲裁裁决的国际可执行性远远超过任何国家法院判决的可执行性”。[193]这一理由同样可以适用于未根据 ICSID 公约进行的 ISDS 仲裁程序，尤其是考虑到《纽约公约》几乎具有普遍的适用范围。[194]在一种相当罕见的情况下，即 ICSID 公约或《纽约公约》在特定执行地生效。事实上，《纽约公约》明确承认“有关承认和承认的多边或双边协定”的有效性。[195]特别是，此类规定执行仲裁裁决的“双边协议”可以采取任何适用的国际投资协议的形式，前提是该协议包含有关在其当事人领土内组成的仲裁庭作出的仲裁裁决的可执行性的规定。[196]而且，即使《纽约公约》适用于根据包含有关以下条款的可执行性条款的国际投资协议作出的仲裁裁决：仲裁裁决，如果该投资条约关于仲裁裁决执行的规定比《纽约公约》的规定更有利，则根据《纽约公约》的规则，该投资条约的规定优先于《纽约公约》的规定，并明确规定适用执行地现行的最有利的法律。[197]

然而，应牢记 ISDS 仲裁裁决的可执行性仍可能存在一些限制。这些限制中最重要的是国家豁免法，它可能对《ICSID 公约》[198]和《纽约公约》下的 ISDS 仲裁裁决的可执行性构成障碍。[199]虽然投资者在寻求针对东道国执行仲裁裁决时经常遇到这些障碍，[200]但作为 ISDS 仲裁裁决债权人的东道国不会面临这些障碍。这种特殊的立场为东道国最终诉诸 ISDS 仲裁程序提供了更有说服力的理由，以履行投资者违反环境和气候变化义务的国际责任。

6 | 结论

本文在对文献和实践进行全面回顾的基础上，分析了 ISDS 是否适合解决涉及环境和气候变化问题的争端，特别是以国际仲裁的形式，以及东道国在 ISDS 仲裁程序中使用反诉的情况。为此，本文强调了 ISDS 仲裁程序作为履行违反气候变化义务的国际责任的手段所发挥的作用，以及国际投资法在证实此类义务方面的作用。

本文讨论了国际仲裁作为和平解决争端的首选手段之一

[185]Zheng and Calamita (n 33) 262–263.
[186]ibid 263.
[187]ibid.
[188]A Broches, ‘The Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of Other States’ (1972) 136 Recueil des Cours 331, 349, discussed by McLachlan (n 6) 445 para 86.
[189]McLachlan (n 6) 445, para 86.
[190]ibid 446, para 89.
[191]ibid 446, para 90.
[192]ibid.
[193]ibid.
[194]United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) ‘Dispute Settlement: Investor-State’ UN Doc UNCTAD/ITE/IIT/30 (May 2003) 63.
[195]New York Convention (n 26) art VII(1).
[196]UNCTAD (n 194) 64 (citing, as examples, the United States/Russia and Lithuania/Sweden bilateral investment treaties).
[197]So would also be the case if the more favourable provisions were of national law of the place of enforcement. New York Convention (n 26) art VII(1) (providing it ‘shall not affect’ the validity of treaties concerning enforcement of arbitral awards, ‘nor deprive any interested party of any right he may have to avail himself of an arbitral award in the manner and to the extent allowed by the law or the treaties of the country where such award is sought to be relied upon’). N Blackaby et al, *Redfern and Hunter on International Arbitration* (6th edn, Oxford University Press 2009) 636, para 11.93 (referring to ‘more favourable local law’).
[198]ICSID Convention (n 27) arts 54 and 55.
[199]New York Convention (n 26) art V(2)(b).
[200]Blackaby et al (n 197) 656 para 11.146 (noting that, ‘whilst the existence of an arbitration agreement is usually held to be a waiver of immunity from jurisdiction, such a waiver is generally not held to extend to immunity from execution’).

20500034, 2023, 2, Downloaded from https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/reciel.12482 by Cayce Sosa Universidad Y Of Pacific Library, on 08/03/2026 [See Terms and Conditions (https://onlinelibrary.wiley.com/terms-and-conditions) on Wiley Online Library for rules of use; OA articles are governed by the applicable Creative Commons License]

根据国际法，包括有关环境和气候变化的国际法。重要的是，据观察，国际仲裁的卓越地位，尤其是在 ISDS 背景下，主要归因于 ISDS 仲裁程序的灵活性和混合性以及 ISDS 仲裁裁决的可执行性。

关于 ISDS 的灵活性，本文讨论了正在进行的 ISDS 改革可能为在 ISDS 仲裁程序的程序框架内履行违反气候变化义务的国际责任带来的机遇。值得注意的是，它侧重于国际仲裁在解决混合争端中的卓越作用，从而使外国投资者等私人当事人承担责任，而不像大多数其他国际争端解决机制那样，专门致力于让国家承担责任。它以投资条约实践新趋势的形式讨论了实质性和程序性投资法改革，并讨论了 ISDS 仲裁程序中反诉的新监管程序框架。

关于ISDS的混合性，本文特别考察了这一特征在ISDS仲裁程序适用法律的构成中如何体现。它解决了可能依赖 ISDS 来促进履行气候变化相关义务的明显悖论，尽管国际投资法和 ISDS 似乎固有的趋势是削弱东道国参与环境保护和气候变化减缓措施的能力，这表明 ISDS 不能直接损害国际法规定的这种能力。它还讨论了投资者如何利用 ISDS 追究东道国违反环境和气候变化义务的责任。还审查了东道国追究外国投资者对类似违规行为负责的可能性，特别是在东道国国内法是投资者根据适用的投资条约承担义务的来源的情况下，作为ISDS仲裁程序的主要法律来源和管辖权。

最后，文章详细分析了 ISDS 中反诉规制的程序和实体方面，以及 ISDS 仲裁裁决在履行违反气候变化义务的国际责任方面的可执行性地位。除了阐明与反诉的提出相关的管辖权来源和实体权利义务的概念外，还考察了ISDS仲裁裁决的可执行性所带来的独特优势，作为支持国际仲裁适用性的一个主要特征。

一般而言，尤其是 ISDS 仲裁程序，旨在解决具有环境和气候变化因素的争端，即使这些因素是作为投资争端的附属解决方案。

总之，本文表明，尽管存在各种局限性，但 ISDS 仲裁程序对于履行气候变化国际责任的适用性是可以自信地肯定的。随着国际投资法经历深刻变革，这一作用的前景仍有待观察，并可能为进一步研究提供沃土。

数据可用性声明

数据共享不适用于本文，因为当前研究期间没有生成或分析数据集

Orcid
迭戈·梅希亚-莱莫斯https://orcid.org/0000-0003-3753-3321

作者简介

Diego Mejía-Lemos（法学硕士、博士）是国际法和争议解决领域的学者和实践者。他拥有纽约大学和新加坡国立大学 (NUS) 等大学的研究生学位。他曾在国际法院和法庭上代表国家出庭，包括在法国巴黎 Freshfields Bruckhaus Deringer 的国际仲裁和国际公法小组工作期间。他还为仲裁庭提供支持，包括在荷兰海牙常设仲裁法院 (PCA) 国际局主持下进行诉讼的仲裁庭。最近，他在新加坡国立大学获得了博士后奖学金，后来被任命为西安交通大学“青年人才”计划的杰出研究副教授。

如何引用本文：Mejía-Lemos D. 投资者与国家争端解决和东道国反诉对于履行气候变化国际责任的适用性。收起。 2023；32(2)：334-347。 doi：10.1111/卷。 12482